

EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 05-02-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====
Processos: TC-023615.989.24-1
TC-023624.989.24-0
Representantes: UP Brasil Administração e Serviços Ltda.
Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.
Representada: Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN
Assunto: Exame prévio de edital do chamamento público nº 01/24,
que tem por objeto o *“credenciamento de empresa(s) facilitadora(s) na aquisição
de gêneros alimentícios, por meio de cartões magnéticos/eletrônicos,
multibenefícios, bandeirados, com arranjo de pagamento aberto, dotados de chip
de segurança para recargas mensais dos benefícios de vale alimentação e vale
refeição”*.
Responsável: Amauri Marquezi de Luca (Diretor-Presidente à época).
Atual Diretor-Presidente: Michel Macahiba Domingues
Advogados cadastrados no e-TCESP: Pedro Henrique Ferreira Ramos
Marques (OAB/SP nº 261.130), Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP nº 288.403)
e Beatriz Bevilacqua D’Auria (OAB/SP nº 311.838).
=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. CHAMAMENTO PÚBLICO. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO. EMPRESA DE ECONOMIA MISTA. LICITAÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.303/2016 E REGULAMENTO PRÓPRIO. CRITÉRIO DE ESCOLHA DA CONTRATADA. VOTAÇÃO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. A CONTRATAÇÃO DE APENAS UMA EMPRESA NÃO SE COADUNA COM O INSTITUTO DO CREDENCIAMENTO. INDEVIDAS EXIGÊNCIAS DE INTEROPERABILIDADE ENTRE OS ARRANJOS DE

PAGAMENTO ABERTO E FECHADO E DE PORTABILIDADE DA EMPRESA GESTORA DOS CARTÕES DE BENEFÍCIOS. FALTA DE REGULAMETAÇÃO LEGAL. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. AUSENTE ILEGALIDADE POR EXPRESSA PREVISÃO NO REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame prévio de edital** do chamamento público nº 01/24, elaborado pela **COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN**, que tem por objeto o *“credenciamento de empresa(s) facilitadora(s) na aquisição de gêneros alimentícios, por meio de cartões magnéticos/eletrônicos, multibenefícios, bandeirados, com arranjo de pagamento aberto, dotados de chip de segurança para recargas mensais dos benefícios de vale alimentação e vale refeição”*.

1.2 Inicialmente, **UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA** asseverou que, nas justificativas para o credenciamento, foram incluídas regras ainda não regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Nesse sentido, destacou a exigência de interoperabilidade entre os arranjos de pagamento aberto e fechado¹ e a imposição de portabilidade da empresa gestora dos cartões de benefícios² (reproduzida no edital)³.

1.3 Por sua vez, **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS** questionou a estipulação de que somente a empresa credenciada que conseguir a votação majoritária dos beneficiários será contratada⁴.

1.4 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi concedida por este E. Plenário.

Na oportunidade, foram solicitados esclarecimentos complementares acerca da exigência de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial⁵, documento que excede o rol taxativo do artigo 69 da Lei nº 14.133/21.

¹ ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (...)

2.1 Justificativa para o Credenciamento dos Prestadores de Serviços (...)

A Lei Federal nº 14.442/2022, à qual está sujeita a CIJUN por estar inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT (CNPJ: 67.237.644/0001-79), introduziu novas regras para as contratações dos benefícios de vale alimentação e refeição tais como: (...)

c) acesso a uma rede maior de estabelecimentos em razão do compartilhamento pelas operadoras de benefícios de sua rede credenciada, para transações de outras marcas, por meio da interoperabilidade;

d) portabilidade de créditos, possibilitando ao beneficiário transferir o crédito acumulado para outra operadora de benefícios, independente da bandeira de pagamento, sem a imposição de taxas

² Vide nota anterior

³ 7.2.17. Decorridos 12 (doze) meses de utilização, os beneficiários poderão requerer a realização de nova votação entre as demais CREDENCIADAS HABILITADAS, podendo haver a portabilidade para outra CREDENCIADA HABILITADA caso o resultado seja diferente do anterior. Neste caso, a nova empresa deverá apresentar as versões atualizadas de seus documentos de habilitação que estiverem vencidos, nos termos do Edital para só posteriormente à análise ser convocada para assinatura do contrato (...)

12.2. Na ocorrência da hipótese prevista no subitem "a" do item 13.7 do edital, o contrato será prorrogado pelas partes até a ocorrência da escolha da nova empresa pelos beneficiários com sua devida contratação, realizando, na oportunidade, a devida portabilidade dos créditos eventualmente existentes nos termos do item 3.4.8 e item 7.2.17. ambos do Termo de Referência (anexo I do Edital).

⁴ 13.7. Somente será efetivado o contrato com a CREDENCIADA HABILITADA mais votada pelos beneficiários, sendo que as demais, permanecerão credenciadas durante toda a vigência do Termo de Credenciamento, com possibilidade de participação nos anos subsequentes nas seguintes hipóteses: a) Desejo dos beneficiários de realizar nova escolha para selecionar qual empresa será a responsável pelo gerenciamento do seu benefício, desde que decorridos 10 (dez) meses de contratação. b) No caso de descumprimento contratual pela CREDENCIADA CONTRATADA, ensejando a rescisão do contrato.

⁵ 7.1.5. Comprovação de Qualificação Econômico-financeira

a) A(s) empresa(s) interessada(s) deverão apresentar Certidão Negativa de Falência ou de Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida com antecedência máxima de 90 (noventa) dias contados da data da apresentação dos documentos no certame. a1) As empresas em situação de recuperação

1.5 Notificada, a **Representada** alegou não se sujeitar à Lei nº 14.133/21, mas exclusivamente à Lei das Estatais e ao seu Regulamento Interno de Licitações e Contratos editado *“nos termos do artigo 40 da L.E., bem como a Portaria CIJUN nº 03/2024 (Documento 04) que regulamenta a utilização do procedimento de credenciamento como forma contratação direta nos termos do caput do artigo 30 da Lei nº 13.303/2016, no âmbito da REPRESENTADA (art. 173, § 3º, da CRFB)”*.

Argumentou, ainda, que os itens 1.1, 21.1 do Edital e 1, 3.1.1, 3.5.1, 3.5.4 e 7.3 do Termo de Referência, que tratam da interoperabilidade entre arranjos aberto e fechado, estão em conformidade com as normas que regem a matéria.

No mesmo sentido, defendeu a legalidade da exigência de portabilidade dos créditos entre empresas gestoras, acrescentando ser possível a troca anual de fornecedores, sem que o colaborador perca o saldo do benefício depositado.

Aduziu que a inviabilidade de competição, decorrente da impossibilidade de ofertas negativas, impõe o uso do credenciamento, no qual entende ser *“possível que o ente público se disponha a contratar todos que tiverem interesse e que preencham as condições por ele estabelecidas ou, em alguns casos, que a escolha se dê pelo usuário do serviço objeto da contratação, como é o caso dos autos”*.

No que tange à certidão negativa de recuperação judicial, repisou o argumento de que não se sujeita à Lei nº 14.133/21, não se lhe aplicando o artigo 69 da citada norma. Argumentou, assim, que seu Regulamento Interno expressamente prevê a exigência das certidões negativas de

judicial ou extrajudicial, detentoras de Certidão Positiva, deverão apresentar, para efeitos de habilitação no certame, Plano de Recuperação devidamente homologado pelo juízo competente e em pleno vigor.

a2) Para (a)s empresa(s) sediada(s) em local(is) em que a verificação é centralizada, será aceita uma única certidão

falência/recuperação judicial ou extrajudicial, dando, desta forma, legalidade à previsão editalícia.

Por fim, expôs ter recebido o pedido de credenciamento de duas empresas do setor.

1.7 O Ministério Público de Contas manifestou-se pela procedência das impugnações.

Anotou que o regulamento interno de contratação direta da Companhia (Portaria nº 03/2024) possibilita que a escolha do contratado recaia sobre o beneficiário direto da prestação, assim como o faz o artigo 79, inciso II, da Lei 14.133/21.

Todavia, anotou que, *“além da necessidade de tornar o credenciamento permanentemente aberto a todos os interessados no objeto, cabe a alteração do método de escolha da credenciada (‘maioria dos beneficiários da CIJUN’ – item 17.1 do Edital), de tal maneira que cada beneficiário indique, de forma direta e pessoal, após avaliação dos materiais de divulgação, e em sintonia com critérios e requisitos suficientemente descritos no edital, a credenciada que lhe traga maior utilidade”*.

Afirmou mais que, caso a Companhia não possua estrutura administrativa suficiente à boa gestão de múltiplos contratos, poderá repensar o modelo de concessão do benefício.

Avaliou que deve também ser revista a *“exigência de certidão negativa de recuperação judicial e extrajudicial (item 7.1.5, ‘a’, do Edital) e, em sendo positiva, de apresentação do plano de recuperação homologado pelo juízo competente (item 7.1.5, ‘a1’, do Edital), não obstante a autorização dada pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CIJUN (Portaria nº 01, de 27 de janeiro de 2023)”*. Nesse aspecto, ponderou terem sido *“ultrapassados os limites legais e constitucionais a serem observados no estabelecimento dos critérios de aferição dos parâmetros de habilitação, pela criação de barreiras à superação*

da crise econômico-financeira não raramente enfrentada por diversas empresas do país, o que contribui para a destruição da fonte produtora e de postos de trabalho, além de prejudicar o interesse de credores”.

Além disso, destacou a *“falta de regulação minimamente suficiente à efetiva implementação da interoperabilidade entre arranjos de pagamento e da portabilidade dos valores creditados nas contas de pagamento, a ser realizada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), respectivamente, por força do disposto no Decreto Federal nº 10.854, de 10 de novembro de 2021 (alterado pelo Decreto Federal nº 11.678, de 30 de agosto de 2023), competindo à representada excluir as cláusulas editalícias envolvidas na matéria”.*

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A **COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN** pretende o *“credenciamento de empresa(s) facilitadora(s) na aquisição de gêneros alimentícios, por meio de cartões magnéticos/eletrônicos, multibenefícios, bandeirados, com arranjo de pagamento aberto, dotados de chip de segurança para recargas mensais dos benefícios de vale alimentação e vale refeição”.*

2.2 Inicialmente, necessário consignar que a CIJUN, por sua natureza de empresa de economia mista, se submete à Lei nº 13.303/16 e a seu regulamento próprio.

A Nova Lei de Licitações, em seu artigo 1º, §1º, dispõe expressamente não serem por ela abrangidas *“as empresas públicas, as*

sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178”.

Além disso, de acordo com seu artigo 189, será esta norma aplicada nos casos em que a legislação faça menção às leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 12.462/2011.

Observa-se, assim, que a Lei das Estatais faz referência ao antigo diploma de licitações em seus artigos 41 e 55, que tratam, respectivamente, da aplicação das normas penais e dos critérios de desempate.

Não obstante, considero que referida disposição não impede o uso complementar do novel diploma de licitação, nos casos em que haja lacunas na norma própria.

Outrossim, a Lei nº 14.133/21, afora ser mais abrangente e pormenorizada, é mais moderna e apresenta avanços não previstos na Lei nº 13.303/16.

Nesse contexto, entendo que as estatais devem observar os princípios gerais da Nova Lei de Licitações e a respectiva jurisprudência.

2.3 Dito isso, é de se destacar que o artigo 79 da Lei nº 14.133/21, cuja aplicabilidade a Companhia pretende afastar, apenas consolidou o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do credenciamento.

Sobre o assunto, destaco decisão deste E. Plenário, sob a relatoria do e. Conselheiro DIMAS RAMALHO, nos autos do processo TC-000200.989.14-3⁶:

“Consabido que o instituto do credenciamento trata-se de negócio jurídico contratual e decorre de interpretação doutrinária e jurisprudencial de nossos Tribunais, porquanto plenamente passível de subsunção aos casos de inexigibilidade de licitação, tendo em vista a inviabilidade de competição, nos termos e princípios preconizados na Lei nº 8.666/93.

Pode-se dizer que o credenciamento é uma espécie de cadastro em que todas as interessadas, habilitadas na forma estabelecida pela

⁶ Sessão Plenário de 09-04-2014.

Administração Pública no ato de chamamento público, prestam determinados tipos de serviços, em condições parelhas de remuneração, consoante ajuste administrativo, sem que uma prestadora suplante os serviços da outra, porquanto não há cláusula de absoluta exclusividade”.

No mesmo sentido foi o voto proferido pelo e. Conselheiro EDGARD CAMARGO RODRIGUES, nos autos dos processos TC-021288.989.22-1 e TC-021473.989.22-6⁷:

“Embora louvável a preocupação externada pelo Relator, não antevejo que, neste caso, a submissão do instrumento convocatório à Lei 8.666 impeça o uso do credenciamento, sobretudo porque a Lei nº 14.133/21 não traz inovação relevante sobre o tema. Ela eleva a panorama legislativo conceitos já amplamente reconhecidos por doutrina e jurisprudência, não havendo cogitar eventual antinomia ou aplicação conjugada dos dois diplomas.

O instituto do credenciamento é largamente utilizado pela Administração e aceito por doutrina e jurisprudência, inclusive nesta Corte de Contas. É uma ferramenta disponível, que se bem utilizada fornece boa solução ao gestor.

Vale lembrar, por exemplo, aprovação por este Tribunal de contratos de credenciamento firmados entre a Secretaria de Estado da Fazenda e instituições financeiras para arrecadação de tributos estaduais, situação que se amolda ao caso ora em exame, pois configurada a inviabilidade de competição (quaisquer interessados que atendam às condições mínimas exigidas estão aptos), sendo a escolha da contratada conferida também a terceiro, o contribuinte(1).

Inegável, portanto, que o instituto não representa novidade, vindo agora expressamente previsto na nova Lei de Licitações. Por isso não creio que condicionar o uso do credenciamento ao uso imediato do novo diploma seja imprescindível, em especial porque essa medida dependeria também de outros fatores, afetos à realidade local.

E ao se considerar – repita-se – que o credenciamento não provém de inovação legislativa, observa-se que a novidade que houve e que motiva a mudança de rumo jurisprudencial é outro fato, qual seja, a proibição de taxa negativa nos contratos de gerenciamento de vale alimentação, este sim o fator que merece nossa primordial atenção.

Nesse contexto, o advento da proibição de desconto ou deságio em taxas de administração de benefícios de vale alimentação e refeição – inicialmente por força da Medida Provisória nº 1.108, de 2022, posteriormente pela Lei nº 14.442/2022(2) – conduz à inevitável remodelação dos negócios jurídicos firmados pela Administração Pública para esse desiderato. Uma vez fatalmente caracterizado o empate entre as propostas, todas com oferta da denominada “taxa

⁷ Sessão Plenária de 12-04-23

zero”, compreensível a preocupação do gestor em relegar ao fator “sorte” a escolha do prestador do serviço, se processado o torneio sob égide da Lei nº 8.666/93.

(...)

Caracterizado aludido cenário, identifica-se possibilidade do uso do credenciamento, sabidamente admitido por doutrina e jurisprudência e hoje assim expressamente definido na Lei nº 14.133/2021: processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados (art. 6º, XLIII)”.

Necessário destacar que, assim como a Lei das Estatais, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CIJUN não disciplina o tema.

Destarte, na esteira do parecer do MPC, entendo que, *“ainda que o referido diploma geral não seja aplicável à representada, deve ser observado o entendimento construído por este Tribunal de Contas a respeito do tema”.*

Na hipótese, a previsão de que *“somente será efetivado o contrato com a credenciada habilitada mais votada pelos beneficiários”*, mostra-se em dissonância com o entendimento deste Tribunal.

Reiteradas têm sido as decisões deste E. Plenário, de que é exemplo o TC-016487.989.24-6⁸, no sentido de que *“não é possível permitir que um procedimento de credenciamento (...) tenha prosseguimento com um critério de seleção (...) que impõe percentual mínimo para assinatura do contrato, mesmo após as licitantes terem cumprido as regras previstas no instrumento convocatório”.*

2.4 Outrossim, indevidas as exigências de interoperabilidade entre os arranjos de pagamento aberto e fechado e de portabilidade da empresa gestora dos cartões de benefícios, pois sua implementação ainda depende de regulamentação, *“a ser realizada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), respectivamente, por força do disposto*

⁸ Sessão Plenária de 04-09-24. Relator Conselheiro DIMAS RAMALHO

no Decreto Federal nº 10.854, de 10 de novembro de 2021 (alterado pelo Decreto Federal nº 11.678, de 30 de agosto de 2023)", como bem observou o MPC.

2.5 Por fim, quanto à participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial, importante lembrar que tais institutos foram criados pela Lei nº 11.101/05, substituindo-se a concordata.

Por aplicação extensiva, os editais passaram a vedar, com fulcro no artigo 31, inciso II, da Lei nº 8.666/93, as empresas que estivessem em tais condições de participarem dos certames licitatórios.

Esses acontecimentos decorreram de uma lacuna havida com a edição da norma, sem que houvesse qualquer mudança na Lei nº 8.666/93.

Todavia, a recuperação judicial e extrajudicial foi introduzida no cenário jurídico com o objetivo de suplantar as deficiências da concordata, possibilitando que as empresas pudessem, de fato, restabelecer-se.

Não por outro motivo, este Plenário editou a Súmula nº 50, como forma de evitar que essas sociedades ficassem alijadas dos procedimentos licitatórios, sem deixar de salvaguardar a Administração Pública.

Já a Lei nº 14.133/21 limita a participação nos certames apenas das empresas em falência, como forma de prestigiar o mecanismo da recuperação. Por esse motivo, este E. Plenário tem decidido não ser mais possível a exigência de documentação complementar das empresas que eventualmente estejam em recuperação judicial ou extrajudicial.

Há de se destacar que a Lei das Estatais não disciplina a matéria, limitando-se a possibilitar a aferição da capacidade econômica e financeira, para fins de habilitação (artigo 58, inciso III).

De outro modo, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CIJUN assim estabelece:

"V. Qualificação econômico-financeira:

(...)

b) Para qualquer contratação, Certidão Negativa do Pedido de Falência ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data de expedição limitada aos 90 (noventa) dias anteriores à abertura da licitação.

b.1. As empresas em situação de recuperação judicial ou extrajudicial, detentoras de Certidão Positiva, deverão apresentar, para efeitos de habilitação no certame, Plano de Recuperação devidamente homologado pelo juízo competente e em pleno vigor”.

Desta forma, ainda que não estejam o Regulamento de Compras e o edital nos exatos moldes da Nova Lei de Licitações, à qual, aliás, não se submete a CIJUN, como já mencionado, seus termos mostram-se em harmonia com o espírito da norma e da jurisprudência desta Corte, ao não impedir a participação de empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que apresentado o devido plano em vigor.

2.6 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) possibilitar a contratação de todas as interessadas que tenham sido credenciadas; e
- b) excluir as exigências de interoperabilidade entre os arranjos de pagamento aberto e fechado e de portabilidade da empresa gestora dos cartões de benefícios;

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório relacionados.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2025.



TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
(11) 3292-3368/3531 - gcseb@tce.sp.gov.br

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

CONSELHEIRO